EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO – CNC, entidade sindical de grau máximo, representante da categoria econômica do comércio, com circunscrição em todo o território nacional, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.423.575/0001-76, com sede no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco B, nº 14, 15º ao 18º andares, Asa Norte, Brasília-DF, CEP nº 70.041-902, endereço eletrônico cncrj@cnc.org.br, por seus advogados abaixo assinados, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento nos artigos 102, inciso I, alíneas "a" e "p", e 103, inciso IX, da Constituição da República e na Lei nº 9.868/99, bem como nos artigos 169 a 178 do Regimento Interno desta Excelsa Corte, propor a presente

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE,
COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR

para postular a declaração de inconstitucionalidade dos arts. 1º a 12, 15, 16 e 21 da Lei nº 14.789/23, pelos fundamentos que passa a aduzir.

I – DA LEGITIMIDADE ATIVA DA REQUERENTE E DA PERTINÊNCIA TEMÁTICA DA MATÉRIA

1. A Lei nº 14.789/2023 dispôs sobre o crédito fiscal decorrente de subvenção para implantação ou expansão de empreendimento econômico e revogou dispositivos do Decreto-Lei nº 1.598/77, da Lei nº 10.637/2002, da Lei nº 10.833/2003 e da Lei nº 12.973/2014, instituindo uma nova sistemática de tributação de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins sobre as subvenções recebidas pelas pessoas jurídicas.

2. Conforme será demonstrado mais adiante, as alterações promovidas pela Lei nº 14.789/2023 encontram-se em flagrante confronto com disposições da Constituição da República, com reflexos danosos para a sociedade em geral, e mais especificamente para as empresas beneficiárias de subvenções, que estão sendo atingidas por um repentino aumento da carga tributária incidente sobre os incentivos fiscais, que compromete a competitividade das empresas, afetando a segurança jurídica e prejudicando o desenvolvimento econômico e social do País.

3. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), como entidade sindical de grau superior, representante, no plano nacional, dos direitos e interesses do comércio brasileiro de bens, serviços e turismo (art. 1º, § 1º, inciso I, do seu Estatuto Social – doc. anexo), está legitimada a arguir a inconstitucionalidade dos referidos artigos, tendo em vista a inteira pertinência da matéria ora invocada, frente às graves lesões aos direitos das empresas do comércio de bens, serviços e turismo que representa.

4. Encontra-se, dessa forma, plenamente atendido o necessário vínculo da pertinência temática, demonstrado pelo liame entre o objeto da ação, a atividade de representação da Requerente e o segmento representado (empresas beneficiadas por subvenções do setor do comércio de bens, serviços e turismo) alcançado pelos efeitos nocivos da norma ora questionada, preenchendo a CNC todos os requisitos de legitimidade para a propositura de ações diretas de inconstitucionalidade, conforme art. 103, inciso IX, da Constituição Federal, o que já restou reconhecido por esta Suprema Corte em inúmeros julgados.

II - DOS ATOS NORMATIVOS IMPUGNADOS

5. A recente Lei nº 14.789/2023, conhecida como "Lei das subvenções", realizou profundas alterações na legislação anterior (artigo 19, §3º, do Decreto-lei 1.598/77 e Lei nº 12.973/2014), para incluir o valor das subvenções para investimentos no conceito de "lucro da exploração" do negócio e passar a tributá-lo.

6. De acordo com a nova legislação, a partir do dia 1º de janeiro de 2024, as subvenções para investimento recebidas pelas empresas passarão a ser tributadas pelo Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ, pela Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, e pelas contribuições ao Programa de Integração Social - PIS e à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS.

7. Eis os dispositivos impugnados da Lei nº 14.789/2023:

"CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º A pessoa jurídica tributada pelo lucro real que receber subvenção da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios para implantar ou expandir empreendimento econômico poderá apurar crédito fiscal de subvenção para investimento, observado o disposto nesta Lei.

Art. 2º Para os fins do disposto no art. 1º desta Lei, considera-se:

I - implantação - o estabelecimento de empreendimento econômico para o desenvolvimento da atividade a ser explorada por pessoa jurídica não domiciliada na localização geográfica do ente federativo que concede a subvenção;

II - expansão - a ampliação da capacidade, a modernização ou a diversificação do comércio ou da produção de bens ou serviços do empreendimento econômico, inclusive mediante o estabelecimento de outra unidade, pela pessoa jurídica domiciliada na localização geográfica do ente federativo que concede a subvenção;

III - crédito fiscal de subvenção para investimento - o direito creditório:

a) decorrente de implantação ou expansão do empreendimento econômico subvencionado por ente federativo;

b) concedido a título de Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ); e

c) passível de ressarcimento ou de compensação com tributos administrados pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda.

CAPÍTULO II

DA HABILITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA

Art. 3º Poderá ser beneficiária do crédito fiscal de subvenção para investimento a pessoa jurídica habilitada pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.

Art. 4º São requisitos para a concessão da habilitação à pessoa jurídica:

I - ser beneficiária de subvenção para investimento concedida por ente federativo;

II - haver ato concessivo da subvenção editado pelo ente federativo anterior à implantação ou à expansão do empreendimento econômico; e

III - haver ato concessivo da subvenção editado pelo ente federativo que estabeleça expressamente as condições e as contrapartidas a serem observadas

pela pessoa jurídica relativas à implantação ou à expansão do empreendimento econômico.

Parágrafo único. Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias da apresentação do pedido de habilitação pela pessoa jurídica sem que tenha havido a manifestação pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, a pessoa jurídica será considerada habilitada.

Art. 5º Observado o direito à ampla defesa e ao contraditório, a habilitação será:

I - indeferida, na hipótese de a pessoa jurídica não atender aos requisitos de que trata o art. 4º desta Lei; ou

II - cancelada, na hipótese de a pessoa jurídica deixar de atender aos requisitos de que trata o art. 4º desta Lei.

CAPÍTULO III

DA APURAÇÃO DO CRÉDITO FISCAL

Art. 6º A pessoa jurídica habilitada poderá apurar crédito fiscal de subvenção para investimento, que corresponderá ao produto das receitas de subvenção e da alíquota de 25% (vinte e cinco por cento) relativa ao IRPJ.

Parágrafo único. O crédito fiscal deverá ser apurado na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) relativa ao período de apuração de reconhecimento das receitas de subvenção.

Art. 7º Na apuração do crédito fiscal, poderão ser computadas somente as receitas de subvenção que:

I - estejam relacionadas à implantação ou à expansão do empreendimento econômico; e

II - sejam reconhecidas após o protocolo do pedido de habilitação da pessoa jurídica.

Art. 8º Na apuração do crédito fiscal, somente poderão ser computadas as receitas:

I - que sejam relacionadas às despesas de depreciação, amortização ou exaustão ou de locação ou arrendamento de bens de capital, relativas à implantação ou à expansão do empreendimento econômico; e

II - que tenham sido computadas na base de cálculo do IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).

§ 1º Não poderão ser computadas na apuração do crédito fiscal:

I - a parcela das receitas que superar o valor das despesas a que se refere o inciso I do caput deste artigo;

II - a parcela das receitas que superar o valor das subvenções concedidas pelo ente federativo; e

III - as receitas decorrentes de incentivos de IRPJ e do próprio crédito fiscal de subvenção para investimento.

§ 2º Para fins do disposto nos incisos I e II do § 1º deste artigo, os valores serão considerados de forma acumulada a partir da data do ato concessivo da subvenção.

§ 3º O disposto no inciso I do caput e no inciso I do § 1º deste artigo não se aplicará na hipótese de subvenção relacionada a bem não sujeito a depreciação, amortização ou exaustão.

§ 4º As receitas de subvenção de que trata o caput deste artigo não serão computadas na base de cálculo da estimativa mensal para fins do IRPJ e da CSLL e deverão ser tributadas no ajuste anual.

CAPÍTULO IV

DA UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO FISCAL

Art. 9º O crédito fiscal de subvenção para investimento devidamente apurado e informado à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil poderá ser objeto de:

I - compensação com débitos próprios, vincendos ou vencidos, relativos a tributos administrados pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, observada a legislação específica; ou

II - ressarcimento em dinheiro.

Art. 10. O pedido de ressarcimento e a declaração de compensação relativos ao crédito fiscal serão recepcionados após o reconhecimento das receitas de subvenção para fins de tributação.

Parágrafo único. Na hipótese de o crédito fiscal não ter sido objeto de compensação, a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil efetuará o seu ressarcimento no vigésimo quarto mês, contado dos termos iniciais de que trata o caput deste artigo.

Art. 11. O valor do crédito fiscal não será computado na base de cálculo do IRPJ, da CSLL, da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Contribuição para o PIS/Pasep) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins).

Art. 12. O crédito fiscal de subvenção para investimento apurado em desacordo com o disposto nesta Lei não será reconhecido pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.

(...)

CAPÍTULO VI

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 15. A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil poderá disciplinar o disposto nesta Lei.

Art. 16. Os valores registrados na reserva a que se refere o art. 195-A da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, em razão da aplicação do disposto no art. 30 da Lei nº 12.973, de 13 de maio de 2014, ou no § 2º do art. 38 do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, somente poderão ser utilizados para:

I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente absorvidas as demais reservas de lucros, com exceção da reserva legal; ou

II - aumento do capital social.

§ 1º Na hipótese do inciso I do caput deste artigo, a pessoa jurídica deverá recompor a reserva à medida que forem apurados lucros nos períodos subsequentes.

§ 2º Os valores de que trata o caput serão tributados caso não seja observado o disposto no § 1º ou seja dada destinação diversa da prevista no caput deste artigo, inclusive nas hipóteses de:

I - capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital social, hipótese em que a base para a incidência será o valor restituído, limitado ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou de subvenções governamentais para investimentos;

II - restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital social, nos 5 (cinco) anos anteriores à data da doação ou da subvenção, com posterior capitalização do valor da doação ou da subvenção, hipótese em que a base para a incidência será o valor restituído, limitada ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou de subvenções governamentais para investimentos; ou

III - integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios.

(...)

Art. 21. Ficam revogados os seguintes dispositivos:

I - inciso V do caput do art. 19 e § 2º do art. 38 do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977;

II - inciso X do § 3º do art. 1º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002;

III - inciso IX do § 3º do art. 1º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003; e

IV - art. 30 da Lei nº 12.973, de 13 de maio de 2014."

8. Conforme será melhor demonstrado adiante, ao assim disciplinar a nova sistemática, a Lei nº 14.789/2023 violou diversos dispositivos constitucionais, quais sejam: art. 153, inciso III; art. 195, inciso I, alíneas "b" e "c" (conceito constitucional de renda e receita); art. 145, § 1º (princípio da capacidade contributiva); art. 5º, *caput*, e inciso XXII (direito de propriedade); art. 150, inciso IV (princípio do não-confisco); art. 1º, 3º e art. 60, § 4º, inciso I (princípio federativo e redução das desigualdades sociais e regionais).

III – DO FUNDAMENTO DA CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL – BREVE ANÁLISE LEGAL DO TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DAS SUBVENÇÕES NO DIREITO BRASILEIRO

9. O tratamento tributário conferido às subvenções é altamente controvertido e complexo, envolvendo uma série de legislações e atos normativos que tentam apaziguar o tema, ora tendendo a afastar a incidência de tributos por não as considerar receita tributável, ora se inclinando a fazer incidir IRPJ, CSLL, PIS e Cofins sobre as mesmas. Por isso é importante traçar um histórico, ainda que sucinto, sobre a evolução legislativa do assunto.

10. As subvenções são tratadas originariamente no Direito Financeiro (Lei 4.320/64, art. 12, §§ 2º e 3º). A referida lei as trata como investimentos do Poder Público, na condição de "Transferências Correntes". Se dividem em: (i) Subvenções Sociais (destinadas a entidades de caráter assistencial ou cultural sem fins lucrativos); (ii) Subvenções Econômicas (destinadas a cobrir despesas de custeio de empresas públicas ou privadas).

11. Até então não havia a previsão de subvenções de investimento. Diante da lacuna legal, a RFB editou o Parecer Normativo CST 142/73, determinando que auxílios recebidos, vinculados ou não a impostos, mesmo destinados a estimular as

atividades econômicas, deveriam ser registrados contabilmente no resultado tributável.

12. A Lei 6404/76 diferenciou o tratamento fiscal/contábil dado as subvenções, estipulando que os valores recebidos a esse título fossem creditados na conta de reserva de capital no patrimônio líquido, o que vigorou até 2007, quando a Lei 11.638 inseriu o art. 195-A à Lei das S/A[1], passando a definir que as subvenções governamentais para investimentos deveriam ser registradas em conta de reserva de incentivos fiscais, sendo excluídas da tributação do IRPJ, o que vigora até os dias atuais.

13. Definida a distinção de tratamento entre subvenções, a legislação ainda permaneceria incerta quanto aos critérios legais para se classificar a subvenção como de investimento, o que somente veio a ocorrer com a edição do art. 38, §2º, do Decreto-lei 1.598/77,[2] orientando que tais valores deveriam ser registrados em reserva de capital, vinculando a utilização à absorção de prejuízos ou à incorporação ao capital social. A norma veio a ser aprimorada pelo Decreto-lei 1.730/79, tendo vigorado até a revogação pela Lei 14.789/23, objeto desta ação.

14. Portanto, a partir do Decreto-lei 1.598/77:

A partir do Decreto-lei 1.598/77:

a. As subvenções para investimento deveriam ser registradas em reserva de capital;
b. Utilização vinculada à absorção de prejuízos ou à incorporação ao capital social.
c. As subvenções para investimento não eram incluídas no “lucro da exploração”.

[1] Lei nº 6.404/76. “Art. 195-A. A assembléia geral poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar para a reserva de incentivos fiscais a parcela do lucro líquido decorrente de doações ou subvenções governamentais para investimentos, que poderá ser excluída da base de cálculo do dividendo obrigatório (inciso I do caput do art. 202 desta Lei).”

[2] Decreto-lei 1.730/79.“Art. 38 (...) § 2º - As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, e as doações, feitas pelo Poder Público, não serão computadas na determinação do lucro real, desde que:”

d. Não havia tributação específica sobre essas subvenções.

e. Não existia crédito fiscal relacionado a essas receitas.

15. Diante das lacunas legais sobre os requisitos para que o incentivo fiscal recebesse o tratamento contábil fiscal de subvenção de investimento, coube à Receita Federal editar atos infralegais criando uma série de requisitos não previstos na lei, entre os quais: (i) intenção do ente estatal de incentivar investimentos; (ii) aplicação da subvenção em investimentos de implantação ou expansão do empreendimento econômico projetado; (iii) que o titular da subvenção seja a mesma pessoa titular do empreendimento econômico[3].

16. Os critérios até então definidos em atos infralegais vieram a ser alterados e consolidados no art. 18 da Lei 11.941/2009, que instituiu o Regime Tributário de Transição (RTT). Posteriormente, a Lei 12.973/2014 revogou o RTT e passou a prever na Seção XI, arts. 30 e parágrafos, o tratamento fiscal específico das Subvenções para Investimento, retornando à exigência de registro em reserva de lucros, condição para excluir tais valores da determinação do lucro-real e, consequentemente, da incidência do IRPJ e da CSLL.

17. A nova legislação não afastou as exigências da Receita Federal, fundamentadas em pareceres e instruções normativas, que ao fim e ao cabo buscavam controlar a realização do investimento, exigindo a intenção expressa do ente estatal de subvencionar, a vinculação plena dos recursos ao investimento e projeto pré-aprovado pelo ente concedente do incentivo fiscal, tudo descrito no art. 198, da IN RFB nº 1700/2017, que regulamenta a Lei 12.973/14.

18. O ponto central da discussão estava na caracterização da subvenção de investimento. Havia um evidente conflito, de um lado entre a legislação federal, mais objetiva, genérica e facilitadora da caracterização da subvenção de investimento, e de outro lado as normas internas e infralegais da Receita Federal, que traziam exigências concretas, específicas, focadas no controle e na fiscalização de tais subvenções, exigências caracterizadas como verdadeiros “decretos autônomos”, pois sem amparo em lei formal.

[3] Cf. Parecer Normativo CST nº 2/78 e 112/78.

19. Para afastar a insegurança jurídica que permeava os incentivos fiscais estaduais e sua caracterização como subvenção de investimento, o Congresso Nacional aprovou a Lei Complementar nº 160/2017, que alterou o art. 30, da Lei 12.973/14, para simplificar o assunto, confira-se a descrição da norma:

> "Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão computadas na determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que somente poderá ser utilizada para: (...)
>
> § 4º. Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstos neste artigo.
>
> § 5º. O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados."

20. A LC 160/2017 foi oriunda do Projeto de Lei Complementar (PLP) nº 54/2015, aprovado em 31/05/2017. Percebe-se na justificativa do projeto de lei, especialmente da inclusão do §4º ao art. 30, da Lei 12.973/14, a clara intenção do legislador de facilitar a exclusão das subvenções de investimento da incidência de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, afastando as exigências infralegais até então impostas pela Receita Federal. Confira-se o texto:

> "Além disso, acolhemos ideia do nobre Deputado Luiz Carlos Hauly e incluímos artigos que deixam claro que os incentivos e benefícios fiscais de ICMS recebidos pelas pessoas jurídicas, desde que esses valores sejam mantidos em conta de reserva no Patrimônio Líquido, são subvenções para investimentos, sobre eles não incidindo, por consequência, IRPJ e CSLL. **Impede-se, com isso, que a Secretaria da Receita Federal do Brasil continue a autuar as empresas beneficiárias de incentivos do ICMS com base em *interpretações***

> ***jurídicas equivocadas***, reforçando a segurança jurídica e garantindo a viabilidade econômica dos empreendimentos realizados (grifo adicionado).” (Parecer do relator do PLP 54/2015 na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados – Dep. Federal Alexandre Baldy (PODE-GO)

21. Mesmo com a simplificação operada pelo art. 30, §4º, da Lei 12.973/14, na forma da redação dada pela LC 160/2017, a Receita Federal permaneceu exigindo os requisitos previstos nas normas infralegais[4], especialmente o art. 198, da IN RFB nº 1700/2017, mantendo o requisito da “intenção expressa” do ente público em conceder o benefício como estímulo à expansão empresarial”, os controles de validade dos incentivos fiscais concedidos pelos Estados e da efetiva implantação dos empreendimentos, e até a sincronia o recebimento e a execução dos investimentos.

22. Esse controle das subvenções estatais foi recentemente deliberado no Congresso Nacional, que aprovou a Lei 14.789/2023, a pretexto de conceder crédito fiscal para empresas que gozam de incentivos fiscais voltados à implantação e expansão de empreendimentos econômicos, abriu espaço para tributar indistintamente todos os incentivos fiscais concedidos pelos Estados, Distrito Federal e Municípios. A partir da nova legislação que começou a vigorar em 01/01/2024, os incentivos fiscais passaram a ter o seguinte tratamento fiscal:

Após a Lei 14.789/23 (Nova Sistemática):

a. As subvenções para investimento agora são consideradas parte do “lucro da exploração”.

b. A partir de **1º de janeiro de 2024,** essas subvenções passaram a ser tributadas pelos seguintes impostos:

   i. **Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ)**

   ii. **Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)**

   iii. **Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS)**

[4] Solução de Consulta COSIT nº 145/2020. Necessidade de demonstração: (i) da intenção do Poder Público de Subvencionar para investimento; e (ii) o incentivo foi contabilizado adequadamente (em reserva de capital ou reserva de incentivos).

iv. Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS)

c. As receitas das subvenções são tributadas no ajuste anual, em 31 de dezembro de cada ano, sem afetar a base de cálculo da estimativa mensal do IRPJ e da CSLL.

d. Os contribuintes têm direito a um **crédito fiscal de 25%** sobre as receitas de subvenção. Esse crédito pode ser utilizado para compensar débitos próprios federais ou ser ressarcido em dinheiro.

   i. Necessária habilitação na RFB; (art. 3º)

   ii. Apresentação do ato de concessão da subvenção para investimento; (art. 4, I)

   iii. A subvenção deve ser anterior ao início do investimento; (art. 4, II)

   iv. A subvenção deve estabelecer as contrapartidas do contribuinte; (art. 4º, III)

   v. Após 30 dias sem análise – haverá deferimento tácito; (art. 4º, P.U)

   vi. O processo de habilitação será aplicado a investimentos em andamento.

e. O crédito não se aplica às subvenções para custeio, que são concedidas para cobrir os custos operacionais da empresa, sem contrapartida do contribuinte.

23. Conforme será exposto, na sistemática anterior prevista na Lei 12.973/14 c/c a LC 160/17, as subvenções estariam excluídas do lucro real das empresas e da base de cálculo de apuração das contribuições CSLL, PIS e COFINS.

24. Será demonstrado ainda que a nova legislação viola a regra matriz de incidência do IRPJ, da CSLL, do PIS e da Cofins, prevista na Constituição Federal, pois contraria os conceitos de renda e receita, descritos no art. 153, inciso III, e no art. 195, inc. I, “b” e “c”, ambos da CF, à medida que incentivos fiscais concedidos por Estados-membros não configuram receita tributável.

25. Como consequência da nova legislação se voltar para a tributação de ingressos que não constituem renda e receita – considerando o conceito constitucional – a nova sistemática de tributação das subvenções viola também o princípio da capacidade contributiva, previsto no art.145 , §1º, da CF, uma vez que, ao fazer incidir tributos sobre recursos não tributáveis, o Estado estará retirando da empresa parte do seu patrimônio, o que desnatura o princípio de proteção à capacidade contributiva dos contribuintes.

26. Ainda dentro desse contexto, uma vez que o tributo incide sobre o patrimônio da empresa, a norma em questionamento se traduzirá em verdadeiro confisco e violação ao direito de propriedade, sendo o primeiro vedado expressamente no art. 150, inc. IV, da CF e o segundo protegido pelo art. 5º, caput, e inc. XXII.

27. Por fim, ao exigir a inclusão no lucro real e no resultado ajustado dos incentivos e benefícios fiscais não vinculados diretamente a projeto de expansão especial, acaba por, sobremaneira, ferir o princípio federativo, uma vez que a União Federal não pode exercer validamente a sua competência tributária sobre elemento inerente à autonomia administrativa de outro ente federado, sem com isso violar diretamente o art. 1º e o art. 60, § 4º, inciso I, da Constituição Federal de 1988, que define a forma federativa do Estado brasileiro.

IV – DA VIOLAÇÃO AO CONCEITO CONSTITUCIONAL DE RENDA E RECEITA

28. Ao definir regras que transformam as subvenções de investimento em receitas que integram a base de cálculo de tributos sobre a renda, como o IRPJ e a CSLL, os arts. 1º a 12, 15, 16 e 21 da Lei nº 14.789/23 contrariam o inciso III do artigo 153 e as alíneas “b” e “c” do inciso I do artigo 195, ambos da Constituição Federal de 1988, que atribuem a União a competência para a instituição de imposto e contribuição sobre as bases econômicas “renda e proventos de qualquer natureza”, “receita ou faturamento” e “lucro”, respectivamente.

29. Para que fiquem claras as contradições e violações constitucionais, faz-se necessário primeiro contextualizar cada um dos dispositivos.

30. O art. 1º da Lei 14.789/23 define o direito do contribuinte que apura o IRPJ pelo regime do lucro real usufruir do crédito fiscal decorrente de subvenção para investimento. O respectivo art. 2º, incisos I, II e III, define os conceitos de

"implantação", "expansão" e "crédito fiscal" e as formas de concessão. Os artigos 3º a 8º da referida lei são regras de formalização do aludido crédito decorrente da "receita" de subvenção para investimentos. Os arts. 9º ao 12 descrevem a forma de utilização do crédito fiscal de subvenção para investimento. O art. 15 consagra regra de delegação de regulamentação da lei para a Receita Federal, o art. 16 delimita a absorção dos valores a título de subvenções de investimento para os fins que indica, quais sejam – absorção de prejuízos e aumento de capital, enquanto o art. 21 da aludida norma revoga a sistemática anterior de não tributação das subvenções.

31. A premissa jurídica trazida para ser examinada por essa Eg. Corte diz respeito à questionável consagração na legislação de que as subvenções são receitas tributáveis do contribuinte. Uma vez acatada a argumentação de que as subvenções não constituem receita tributável, configurando apenas uma renúncia fiscal operada pelo ente público subvencionante, a conclusão inevitável será de que os arts. 1º, 2º e 21 da Lei 14.789/23 são inconstitucionais, e assim como eles, também os demais arts. 3º a 12, 15 e 16, que dispõem sobre a formalização do direito de crédito atacado.

32. O tratamento jurídico dado às subvenções pelos arts. 1º, 2º e 21 da Lei 14.789/23 viola o inciso III do artigo 153 e alíneas "b" e "c" do inciso I do artigo 195, ambos da Constituição Federal de 1988, porque parte da premissa de que os incentivos fiscais denominados subvenções para investimento constituem receita passível de ser tributada pelo IRPJ, CSLL, PIS e Cofins.

33. A matéria suscitada guarda estrita correlação com diversos temas já julgados no Supremo Tribunal Federal, que reiteradamente tem declarado a inconstitucionalidade de normas que indevidamente tributam ingressos financeiros, que não podem ser considerados como receita tributável.

34. Caso emblemático foi tratado pelo RE 574.706 (Tema 69), em que a Corte Suprema decidiu que o ICMS não integra a base de cálculo de tributos sobre o faturamento, por não ser receita que compõe o faturamento do contribuinte. Confira-se:

> "(...) 3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo ele na definição de faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal. **O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da Cofins.** 3. Se o art. 3º, § 2º, inc. I, in fine, da

> Lei 9.718/1998 excluiu da base de cálculo daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os Estados, deve ser enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial decorrente do regime de não cumulatividade em determinado momento da dinâmica das operações. (...)" (RE 574.706, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 15.3.17, DJe-223 29.9.17 e p. 2.10.17)

35. Outro precedente importante deste eg. STF aplicável à matéria sob análise é o RE 606.107 (Tema 283), de relatoria da e. Min. Rosa Weber, em que se verificou a inconstitucionalidade da incidência de PIS e Cofins não cumulativos sobre créditos de ICMS transferidos a terceiros, sob o argumento de que estes não integram o conceito constitucional de receita contido no art. 195, I, "b", da Constituição. Confira-se:

> "Pois bem, **o conceito constitucional de receita, acolhido pelo art. 195, I, "b", da CF, não se confunde com o conceito contábil**. Isso, aliás, está claramente expresso nas Leis 10.637/02 (art. 1º) e Lei 10.833/03 (art. 1º), que determinam a incidência da contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS não cumulativas sobre o total das receitas, "independentemente de sua denominação ou classificação contábil".
>
> Não há, assim, que buscar equivalência absoluta entre os conceitos contábil e tributário.
>
> Ainda que a contabilidade elaborada para fins de informação ao mercado, gestão e planejamento das empresas possa ser tomada pela lei como ponto de partida para a determinação das bases de cálculo de diversos tributos, de modo algum subordina a tributação. Trata-se, apenas, de um ponto de partida. Basta ver os ajustes (adições, deduções e compensações) determinados pela legislação tributária. A contabilidade constitui ferramenta utilizada também para fins tributários, mas moldada nesta seara pelos princípios e regras próprios do Direito Tributário.
>
> Conforme adverte José Antonio Minatel: "há equívoco nessa tentativa generalizada de tomar o registro contábil como o elemento definidor da natureza dos eventos registrados. O conteúdo dos fatos revela a natureza pela qual espera-se sejam retratados, não o contrário".

> **Quanto ao conteúdo específico do conceito constitucional, a receita bruta pode ser definida como o ingresso financeiro que se integra no patrimônio na condição de elemento novo e positivo, sem reservas ou condições**, na esteira da clássica definição que Aliomar Baleeiro cunhou acerca do conceito de receita pública: "Receita pública é a entrada que, integrando-se no patrimônio público sem quaisquer reservas, condições ou correspondências no passivo, **vem acrescer o seu vulto, como elemento novo e positivo**."
>
> Ricardo Mariz de Oliveira especifica ser a receita "algo novo, que se incorpora a um determinado patrimônio", constituindo um "dado positivo para a mutação patrimonial".
>
> **O aproveitamento dos créditos de ICMS por ocasião da saída imune para o exterior não gera, de modo algum, receita tributável**. Cuida-se de mera recuperação do ônus econômico advindo do ICMS, assegurada expressamente pelo art. 155, § 2º, X, "a", da Constituição Federal." (STF, RE 606.107, Tema 283, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2013, DJE 25/11/2013.)

36. Considerando que o conceito constitucional de receita tributável é o "*ingresso financeiro que se integra no patrimônio na condição de elemento novo e positivo, sem reservas ou condições*", subvenções (que são apenas uma espécie de redução de custos do contribuinte, e não um acréscimo patrimonial) não podem ser consideradas receitas do contribuinte, a serem contabilizadas em reserva de lucros, pois não configuram renda para fins de tributação do IRPJ, da CSLL, do PIS e da Cofins.

37. Tal conclusão também pode ser extraída do julgamento do REsp 1.836.082, em que o STJ definiu que descontos concedidos por fornecedor a varejista não integram a base de cálculo das contribuições ao PIS e Cofins, pois parcelas redutoras do custo não caracterizam receita:

> "(...) BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS. INGRESSO PATRIMONIAL NOVO. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS POR VAREJISTA COM DESCONTO CONCEDIDO POR FORNECEDORES. **PARCELA REDUTORA DO CUSTO QUE NÃO CARACTERIZA RECEITA DO COMPRADOR**. (...) III –

> Consoante previsto nos arts. 1º, § 3º, V, *a*, das Leis ns. 10.637/2002 e 10.883/2003, a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, no regime não cumulativo, consiste no total de receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil, razão pela qual o **conceito jurídico de receita não se vincula àquele veiculado pela ciência das finanças**. Precedente do STF. (...) VI – **Os descontos concedidos pelo fornecedor ao varejista**, mesmo quando condicionados a contraprestações vinculadas à operação de compra e venda, **não constituem parcelas aptas a possibilitar a incidência da contribuição ao PIS e da COFINS a cargo do adquirente**. (...)" (STJ, REsp 1.836.082, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/04/2023.)

38. Nessa mesma ocasião, a Relatora Ministra Regina Helena Costa, valendo-se de valiosas doutrinas sobre o tema, assentou o seguinte:

> "**Aliomar Baleeiro, há muito, definiu receita como** entrada qualificada, isto é, **aquela que passa a integrar o patrimônio da pessoa jurídica, como elemento novo e positivo** (*Uma Introdução à Ciência das Finanças*. 2ª ed. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1958. p. 158), **concepção também esposada por Geraldo Ataliba**:
>
> > *O conceito de receita refere-se a uma espécie de entrada. Entrada é todo o dinheiro que ingressa nos cofres de uma entidade.* ***Nem toda entrada é uma receita. Receita é a entrada que passa a pertencer à entidade. Assim, só se considera receita o ingresso de dinheiro que venha a integrar o patrimônio da entidade que o recebe****. As receitas devem ser escrituradas separadamente das meras entradas. É que estas não pertencem à entidade que as recebe. Têm caráter eminentemente transitório. Ingressam a título provisório, para saírem, com destinação certa, em breve lapso de tempo* (*Estudos e Pareceres de Direito Tributário*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1978, Vol. 1, p. 85 - destaquei).
>
> Ignoradas tais diretrizes, **adverte Paulo de Barros Carvalho, permite-se a tributação de valores não pertencentes ao**

> **contribuinte, desvirtuando "completamente o sistema constitucional tributário brasileiro, atingindo o sujeito passivo em quantias que este não está apto a suportar, violando os princípios da capacidade contributiva e do não-confisco**" (*Direito Tributário: linguagem e método*. 6ª ed. São Paulo: Noeses, 2015, p. 837)." (STJ, REsp 1.836.082, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/04/2023.)

39. Sobre o conceito de renda e proventos, Paulo Ayres Barreto afirma que:

> "A expressão *renda* e proventos de qualquer natureza é de ser interpretada, nos estritos termos em que constitucionalmente plasmada, como **acréscimo a um dado conjunto de bens e direitos (patrimônio)**, pertencente a uma pessoa (física ou jurídica), observado um lapso temporal necessário para que se realize o cotejo entre determinados ingressos, de um lado, e certos desembolsos, de outro. Tomaremos a expressão proventos de qualquer natureza como espécie do gênero *renda*, **pressupondo-se sempre a verificação de efetivo acréscimo patrimonial**."[5]

40. Roque Antonio Carrazza também ensina o seguinte:

> "(...) "Renda e proventos de qualquer natureza", para fins de tributação específica, são os **ganhos econômicos do contribuinte, gerados por seu capital, por seu trabalho ou pela combinação de ambos**, e apurados após o confronto das entradas e saídas verificadas em seu patrimônio, num certo lapso de tempo. **Para que haja renda e proventos de qualquer natureza é imprescindível que o capital, o trabalho ou a conjugação de ambos produzam, entre dois momentos temporais, riqueza nova**, destacada daquela que lhe deu origem e capaz de gerar outra. **Somente tais acréscimos patrimoniais poderão ser alcançados pela exação em foco, sob pena de virem extrapolados os limites postos pela Constituição Federal. Portanto, renda é disponibilidade de riqueza nova**, havida em dois momentos distintos. (...) De fato, esta riqueza nova,

[5] BARRETO, Paulo Ayres. *Imposto de renda e preços de transferência*. São Paulo: Dialética, 2001, p. 72.

havida entre dois momentos temporais é o núcleo do imposto sobre a renda."[6]

41. Os incentivos fiscais concedidos pelos Entes da Federação são renúncias fiscais, considerados auxílios tributários que visam incentivar o desenvolvimento econômico de determinadas atividades que interessam ao Poder Público, o que pode ocorrer de várias maneiras: desenvolver um novo mercado na região; incentivar a competitividade entre empresas do setor; gerar empregos; aumentar a renda da população, sempre voltado ao atingimento maior do interesse público.

42. Incentivos fiscais caracterizados como subvenção não geram riqueza nova, não produzem lucro, não acrescem o patrimônio do contribuinte-subvencionado. O auxílio financeiro transferido pelos entes federativos via renúncia fiscal não impacta no patrimônio do subvencionado, somente realiza o plano de desenvolvimento econômico daquele ente para a promoção do interesse público.

43. Não gerando riqueza nova, que se incorpora ao patrimônio, o recebimento de subvenções pelas empresas não constitui hipótese de incidência do IRPJ e da CSLL, que é a aquisição de renda que produza o acréscimo do patrimônio, o lucro.

44. De igual modo, as subvenções não integram a base de cálculo do PIS e da Cofins, que incidem sobre a receita ou faturamento, pressupondo um ingresso financeiro que se integre no patrimônio do contribuinte na condição de elemento novo e positivo, sem reservas ou condições. Dessa forma, a Lei nº 14.789/23 extrapola as bases de cálculo definidas pela Constituição Federal, ferindo de morte as limitações constitucionais ao poder de tributar.

45. Assim, demonstrado que os arts. 1º a 12,15, 16 e 21 da Lei nº 14.789/23 conferem tratamento de receita tributável às subvenções e que tal procedimento legal viola a regra matriz de incidência do IRPJ, da CSLL, do PIS e da Cofins, descritas nos arts. 153, inciso III, e 195, inciso I, alíneas "b" e "c", da Constituição Federal, merece ser reconhecida a inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados.

[6] Roque Antonio Carrazza. Revista Dialética de Direito Tributário n. 154, p. 109

V – DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA

46. O princípio da capacidade contributiva está previsto no parágrafo primeiro do artigo 145 da Constituição Federal, a seguir transcrito.

> "Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:
>
> (...)
>
> § 1º - Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte."

47. Esta Corte Suprema já assentou que o conceito constitucional de receita deve ser definido e interpretado sob o prisma do princípio da capacidade contributiva:

> "Com a EC 20/1998, que deu nova redação ao art. 195, inciso I, da Lei Maior, passou a ser possível a instituição de contribuição para o financiamento da Seguridade Social alternativamente sobre o **faturamento ou a receita** (alínea "b"), conceito este mais largo, é verdade, mas nem por isso uma carta em branco nas mãos do legislador ou do exegeta. **Trata-se de um conceito constitucional, cujo conteúdo, em que pese abrangente, é delimitado, específico e vinculante, impondo-se ao legislador** e à Administração Tributária. Cabe ao intérprete da Constituição Federal **defini-lo, à luz** dos usos linguísticos correntes, dos postulados e **dos princípios constitucionais tributários, dentre os quais sobressai o princípio da capacidade contributiva** (art. 145, § 1º, da CF)." (STF, RE 606.107, Tema 283, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2013, DJE 25/11/2013.)

48. Dessa forma, o princípio da capacidade contributiva deve orientar o legislador na instituição de tributos incidentes sobre a renda ou receita, de forma que estes só

incidam sobre acréscimos patrimoniais tributáveis, isto é, que revelem a capacidade econômica de contribuir:

> "Na qualidade de regra jurídica, a **capacidade contributiva impõe ao legislador** o dever de, na determinação do fato gerador dos impostos (e das contribuições com fato gerador típico de imposto), escolher, para integrar o antecedente normativo, **eventos que revelem riqueza passível de sofrer a imposição fiscal**. De outro lado, o princípio da capacidade contributiva apregoa que, **na definição da base de cálculo dos tributos, o legislador deve estabelecer critérios de quantificação que mensurem, *da forma mais precisa possível,* o conteúdo econômico do fato gerador**.[7]
>
> "A capacidade contributiva objetiva refere-se ao critério de distinção entre os contribuintes, eis que a hipótese tributária da exação deve contemplar, no antecede normativo, situação de fato ou direito que, objetivamente, **revele capacidade econômica de contribuir** com os gastos públicos. (...) Após essas considerações teóricas, é fácil perceber que, **quando não se trata de receita da própria pessoa jurídica recebedora do ingresso ou entrada de natureza financeira, não há autêntica expressão de capacidade contributiva**."[8]

49. Nesse mesmo sentido, ensina José Antônio Minatel:

> "De qualquer modo, embora o conceito de receita seja mais largo que o de faturamento, **nem todo ingresso ou lançamento contábil a crédito constitui receita tributável. A análise da amplitude da base econômica "receita" precisa ser analisada sob a perspectiva da capacidade contributiva**. Não pode o legislador

[7] Paulo Vitor Vieira da Rocha, Substituição Tributária e Proporcionalidade: Entre capacidade contributiva e praticabilidade. São Paulo. Quartier Latin, 2012, p. 199.

[8] Ricardo Mariz de Oliveira, Aspectos Polêmicos do PIS-COFINS, São Paulo, 2013, p. 220/221.

> fazer incidir contribuição sobre indenizações ou ressarcimentos e recuperações de custos tributários."[9]

50. Quanto à aplicação do princípio da capacidade contributiva ao imposto de renda das pessoas jurídicas, Roque Antonio Carrazza dispõe:

> "Reduzindo a idéia à dimensão mais simples, só enquanto aufere lucros é que poderá ser validamente tributada a esse título. Ou, como quer Klaus Tipke, "o princípio da capacidade contributiva determina, em seu conteúdo: (...) toda empresa deve pagar impostos de acordo com o montante de seu lucro". **Não é dado a este imposto absorver, ainda que em parte, o patrimônio da empresa, mas, apenas uma parcela razoável de seu lucro**. É importante termos presente, neste passo, que só deve compor a base de cálculo do IRPJ o dinheiro que ingressa nos cofres da empresa em razão do exercício da sua atividade principal e com foros de permanência. (...) Em suma, **o IRPJ estará irremediavelmente descaracterizado se sua base de cálculo levar em conta qualquer ingresso que não se incorpore ao patrimônio da empresa, aumentando-lhe a riqueza. Isso obrigaria a empresa a magoar uma parcela de seu patrimônio, recolhendo imposto sobre "lucro que não existiu" e, assim, prejudicando suas atividades produtivas, desrespeitando seu direito de propriedade** e tendendo a levá-la à insolvência." [10]

51. A doutrina e a jurisprudência são unânimes no sentido de que o IRPJ, a CSLL, o PIS e a Cofins devem incidir somente sobre o ingresso de riqueza econômica, que represente aumento do patrimônio, sobre parcela razoável do lucro, não podendo de modo algum absorver parte do patrimônio da empresa, sob pena de violação ao princípio da capacidade contributiva.

---

[9] MINATEL, José Antônio. Conteúdo do Conceito de Receita e Regime Jurídico para a sua Tributação, MP, 2005, p. 218-219, 222, 224 e 259.

[10] CARRAZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário, 27ª edição, Malheiros Editores, São Paulo, 2012, p. 140/141.

52. Assim também sob o aspecto acima aludido, os arts. 1º a 12,15, 16 e 21 da Lei nº 14.789/23 devem ser considerados inconstitucionais, pois, ao adotarem como premissa válida que incentivos fiscais são considerados receitas tributáveis pelo IRPJ e CSLL, a Fazenda Nacional desvirtua a matriz de incidência destes impostos incidentes sobre a renda, violando o princípio da capacidade contributiva, assegurado no art. 145, §1º, da CF.

VI – DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO NÃO-CONFISCO E AO DIREITO DE PROPRIEDADE

53. A incidência de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins sobre as subvenções, decorrente da nova sistemática instituída pela Lei nº 14.789/2023, absorve parte do patrimônio da empresa, sem que este tenha sido acrescido por nova riqueza, se traduzindo em verdadeiro confisco e violação ao direito de propriedade, em contrariedade ao princípio da capacidade contributiva e aos arts. 5º, caput, e inciso XXII; 150, inciso IV, e 145, § 1º, da CF, razão pela qual deve ser declarada sua inconstitucionalidade.

54. Eduardo Marcial Ferreira Jardim define confisco da seguinte forma:

> "Confisco. Em direito tributário, o vocábulo é utilizado em sentido estrito, significando, assim, o ato pelo qual o Fisco adjudica bens do contribuinte. Cumpre ponderar que **a tributação de natureza confiscatória é absolutamente proibida, em face de inúmeros primados constitucionais que protegem a propriedade, a teor do princípio assegurador do direito de propriedade e do postulado da capacidade contributiva**."[11]

55. A doutrina de Roque Antônio Carrazza bem demonstra que a prática de cobrar tributos sem observar a capacidade contributiva do contribuinte leva à violação do direito de propriedade, podendo representar até o confisco de bens do particular. Confira-se:

[11] JARDIM, Eduardo Marcial Ferreira. Dicionário jurídico tributário. 5. ed. São Paulo: Dialética, 2005, p. 66.

> "Estamos convencidos de que o **princípio da não-confiscatoriedade**, contido no art. 150, IV, da CF (pelo qual é vedado "utilizar tributo com efeito de confisco"), **deriva do princípio da capacidade contributiva**. Realmente, as leis que criam impostos, ao levarem em conta a capacidade econômica dos contribuintes, não podem compeli-los a colaborar com os gastos públicos além de suas possibilidades. Estamos vendo que **é confiscatório o imposto que** (...) **não leva em conta suas capacidades contributivas**.
>
> O **princípio da não confiscatoriedade limita o direito que as pessoas políticas têm de expropriar bens privados**. Assim, os impostos devem ser graduados de modo a não incidir sobre as fontes produtoras de riqueza dos contribuintes e, portanto, a não atacar a consistência originária de suas fontes de ganho. É confiscatório o tributo que incide sobre correções monetárias, que, como se sabe, não revelam aumento de riqueza (e, nesta medida, aumento de capacidade contributiva), mas simples recomposições do valor de troca da moeda. Também padece desta inconstitucionalidade o tributo que alcança meros sinais exteriores de riqueza, ou seja, indícios, não confirmados pelos fatos, de aumento da aptidão econômica do contribuinte."[12]

56. Esse Eg. STF tem decidido ser inconstitucional por violar o direito de propriedade a prática reiterada das autoridades fiscais de utilizar ficções ou presunções visando a facilitação do trabalho de cobrar impostos. Confira-se:

> "A Constituição consagrou o devido processo legal material (art. 5º, LIV), o princípio da estrita legalidade tributária (art. 150, I) e o **direito à propriedade** (art. 5º, caput). **Esses marcos constitucionais condicionam a atuação das autoridades fiscais de todos os níveis, impedindo-as de utilizar ficções ou presunções imoderadas, desproporcionais ou cuja única justificativa seja a**

[12] CARRAZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 20 ed. rev. ampl. e atual., até a EC nº 44/2004. Malheiros Editores: São Paulo, 2004, pp. 93 – 94.

> **facilitação do trabalho do agente público**. (Voto Min. Joaquim Barbosa, RE 611.586-PR, STF-Plenário, julg. 03/04/2013.)

57. Assim também sob o aspecto acima aludido, os arts. 1º a 12,15, 16 e 21 da Lei nº 14.789/23 devem ser considerados inconstitucionais, pois, ao adotarem como premissa válida que incentivos fiscais são considerados receitas tributáveis pelo IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, a Fazenda Nacional está tributando o patrimônio do contribuinte e não o lucro, incorrendo assim em violação ao direito de propriedade assegurado no art. 5º, caput, da CF.

VII – DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL FEDERATIVO

58. O princípio federativo, pedra fundamental da constituição do Estado brasileiro, não pode ser ameaçado nem menos por Emenda à Constituição (CF, art. 60, § 4º), constituindo cláusula pétrea, e pressupondo a noção de igualdade entre os entes políticos que compõem a Federação, conforme ressalta Geraldo Ataliba:

> "Exsurge a Federação como a associação de Estados (*foedus, foederis*) para formação de novo Estado (o federal) com repartição rígida de atributos da soberania entre eles. Informa-se seu relacionamento pela 'autonomia recíproca da União e dos Estados, sob a égide da Constituição Federal' (Sampaio Dória), caracterizadora dessa igualdade jurídica (Ruy Barbosa), dado que ambos extraem suas competências da mesma norma (Kelsen). Daí cada qual ser supremo em sua esfera, tal como disposto no Pacto Federal (Victor Nunes)."[13]

59. A igualdade jurídica e a supremacia dos entes da Federação restam feridas quando a União interfere no âmbito de autonomia dos demais entes, tributando incentivos fiscais por eles concedidos.

[13] ATALIBA, Geraldo. *República e constituição.* São Paulo: Revista dos Tribunais, 1985. p. 10.

60. Ao assim fazer, a União Federal, ainda que indiretamente, acaba por interferir no âmago da política fiscal, econômica e tributária, levada a efeito pelos governos locais, que também são soberanos em sua esfera de atuação.

61. As subvenções são atreladas a diferentes intenções e políticas públicas dos entes locais, que vão desde motivos sociais até os econômicos, destinados a uma desoneração ou estímulo de determinado setor.

62. Ao conceder uma subvenção, os estados e municípios visam fomentar toda uma política econômica e social para o desenvolvimento de seu território, como, por exemplo, desenvolver determinado setor agrícola, industrial ou comercial, gerar empregos e renda para a sua população, integrar o território local, reduzir desigualdades econômicas e sociais regionais, entre outros fundamentos.

63. Ratificar a tributação federal sobre esses valores, como pretende a Lei nº 14.789/2023, é permitir que a União interfira e mitigue o próprio alcance da política econômica imaginada por aqueles estados e municípios que concederam a subvenção, o que é inadmissível em face dos limites impostos pelo princípio federativo.

64. A União não pode exercer validamente a sua competência tributária sobre elemento inerente à autonomia administrativa de outro ente federado. Isso representaria uma violação direta ao art. 1º da Constituição Federal, que define a forma federativa do Estado brasileiro, conforme assevera Leandro Paulsen:

> "(...) Entendimento contrário **ofenderia o princípio federativo**, na medida em que **tributar crédito de ICMS implica intervir na tributação estadual, afetando a eficácia das imunidades e incentivos** e fazendo com que, à impossibilidade de tributação ou renúncia tributária dos Estados corresponda tributação pela União, em **transferência de recursos absolutamente desarrazoada, contrária à finalidade das normas de imunidade ou de incentivos**."[14]

[14] PAULSEN, Leandro. Direito Tributário - Constituição e Código Tributário à Luz da Doutrina e da Jurisprudência. 15ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013. p. 524.

65. O assunto também já foi pacificado pelo eg. STJ no EREsp 1.517.492, ao definir a impossibilidade de inclusão de crédito presumido de ICMS nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL:

> "(...) ICMS. CRÉDITOS PRESUMIDOS CONCEDIDOS A TÍTULO DE INCENTIVO FISCAL. INCLUSÃO NAS BASES DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA - IRPJ E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. INVIABILIDADE. PRETENSÃO FUNDADA EM ATOS INFRALEGAIS. **INTERFERÊNCIA DA UNIÃO NA POLÍTICA FISCAL ADOTADA POR ESTADO-MEMBRO. OFENSA AO PRINCÍPIO FEDERATIVO E À SEGURANÇA JURÍDICA**. BASE DE CÁLCULO. OBSERVÂNCIA DOS ELEMENTOS QUE LHES SÃO PRÓPRIOS. **RELEVÂNCIA DE ESTÍMULO FISCAL OUTORGADO POR ENTE DA FEDERAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO FEDERATIVO**. ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. INCONSTITUCIONALIDADE ASSENTADA EM REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE N. 574.706/PR). AXIOLOGIA DA *RATIO DECIDENDI* APLICÁVEL À ESPÉCIE. CRÉDITOS PRESUMIDOS. PRETENSÃO DE CARACTERIZAÇÃO COMO RENDA OU LUCRO. IMPOSSIBILIDADE.
> (...) III – Ao considerar tal crédito como lucro, o entendimento manifestado pelo acórdão paradigma, da 2ª Turma, **sufraga, em última análise, a possibilidade de a União retirar, por via oblíqua, o incentivo fiscal que o Estado-membro, no exercício de sua competência tributária, outorgou**. IV – **Tal entendimento leva ao esvaziamento ou redução do incentivo fiscal legitimamente outorgado pelo ente federativo**, em especial porque fundamentado exclusivamente em atos infralegais, consoante declinado pela própria autoridade coatora nas informações prestadas. V – O modelo federativo por nós adotado abraça a concepção segundo a qual a distribuição das competências tributárias decorre dessa forma de organização estatal e por ela é condicionada. VI – Em sua formulação fiscal, revela-se o princípio federativo um autêntico sobreprincípio regulador da repartição de competências tributárias e, por isso mesmo, elemento informador primário na solução de conflitos nas relações entre a União e os demais entes federados. VII – A

Constituição da República atribuiu aos Estados-membros e ao Distrito Federal a competência para instituir o ICMS – e, por consequência, outorgar isenções, benefícios e incentivos fiscais, atendidos os pressupostos de lei complementar. VIII – **A concessão de incentivo por ente federado, observados os requisitos legais, configura instrumento legítimo de política fiscal para materialização da autonomia consagrada pelo modelo federativo. Embora represente renúncia a parcela da arrecadação, pretende-se, dessa forma, facilitar o atendimento a um plexo de interesses estratégicos para a unidade federativa, associados às prioridades e às necessidades locais coletivas**. IX – **A tributação pela União de valores correspondentes a incentivo fiscal estimula competição indireta com o Estado-membro, em desapreço à cooperação e à igualdade, pedras de toque da Federação**. X – **O juízo de validade quanto ao exercício da competência tributária há de ser implementado em comunhão com os objetivos da Federação, insculpidos no art. 3º da Constituição da República, dentre os quais se destaca a redução das desigualdades sociais e regionais (inciso III)**, finalidade da desoneração em tela, ao permitir o barateamento de itens alimentícios de primeira necessidade e dos seus ingredientes, reverenciando o princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento maior da República Federativa brasileira (art. 1º, III, C.R.). XI – Não está em xeque a competência da União para tributar a renda ou o lucro, mas, sim, a **irradiação de efeitos indesejados do seu exercício sobre a autonomia da atividade tributante de pessoa política diversa, em desarmonia com valores éticos-constitucionais inerentes à organicidade do princípio federativo**, e em atrito com o princípio da subsidiariedade, que reveste e protege a autonomia dos entes federados. XII – O abalo na credibilidade e na crença no programa estatal proposto pelo Estado-membro acarreta desdobramentos deletérios no campo da segurança jurídica, os quais não podem ser desprezados, porquanto, **se o propósito da norma consiste em descomprimir um segmento empresarial de determinada imposição fiscal, é inegável que o ressurgimento do encargo, ainda que sob outro figurino, resultará no repasse dos custos adicionais às mercadorias, tornando inócua, ou quase, a**

> **finalidade colimada pelos preceito legais**, aumentando o preço final dos produtos que especifica, integrantes da cesta básica nacional. XIII – A base de cálculo do tributo haverá sempre de guardar pertinência com aquilo que pretende medir, não podendo conter aspectos estranhos, é dizer, absolutamente impertinentes à própria materialidade contida na hipótese de incidência. (...)" (STJ, EREsp 1.517.492, Rel. Min. Og Fernandes, Red. Para o acórdão Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 08/11/2017, DJE 01/02/2018.)

66. Portanto, a União, ao instituir o IRPJ, a CSLL, o PIS e a Cofins sobre as subvenções recebidas pelas pessoas jurídicas, extrapola a sua competência privativa tributária e adentra na dos outros entes federativos, ao anular parcialmente os benefícios fiscais.

67. Assim, os arts. 1º a 12, 15, 16 e 21 da Lei nº 14.789/23 contrariam o princípio federativo e esvaziam a tentativa de redução das desigualdades sociais e regionais, devendo ser declarados inconstitucionais, por violação ao arts. 1º, 3º e 60, § 4º, inciso I, da Constituição Federal.

VIII – DA TUTELA CAUTELAR

68. Conforme amplamente demonstrado acima, os arts. 1º a 12, 15, 16 e 21 da Lei nº 14.789/2023 encontram-se em flagrante confronto com as disposições da Constituição Federal.

69. O ***fumus boni iuris*** está demonstrado com base em tudo o que foi acima exposto, fundamentado em numerosas e indubitáveis manifestações doutrinárias e da jurisprudência consolidada dos eg. Tribunais Superiores, constatando-se, de forma bastante clara e evidente, a afronta à Constituição Federal: art. 153, inciso III; art. 195, inciso I, alíneas "b" e "c" (conceito constitucional de renda e receita); art. 145, § 1º (princípio da capacidade contributiva); art. 5º, *caput*, e inciso XXII (direito de propriedade); art. 150, inciso IV (princípio do não-confisco); art. 1º, 3º e art. 60, § 4º, inciso I (princípio federativo e redução das desigualdades sociais e regionais).

70. O **periculum in mora**, por sua vez, está caracterizado pelos danos irreparáveis que os referidos dispositivos da Lei nº 14.789/2023 têm provocado às empresas contribuintes. Sua aplicação atinge as pessoas jurídicas beneficiárias de subvenções, ocasionando graves prejuízos a estas com a imposição de uma nova e inconstitucional incidência tributária federal sobre renda e receita (IRPJ, CSLL, PIS e Cofins), abarcando valores que não representam acréscimo patrimonial das empresas, mas meros incentivos fiscais (redução de custos) no âmbito de políticas setoriais de incentivo.

71. Dessa forma, além de colocar em risco as atividades das empresas beneficiárias de subvenções, a Lei nº 14.789/2023 produz inegáveis danos também à toda a sociedade brasileira, com o desequilíbrio da carga tributária, a mitigação das políticas públicas regionais de desenvolvimento e o consequente impacto nos preços pagos pelos consumidores finais das cadeias de produção e comercialização em que essas empresas estão inseridas.

72. As consequências nocivas da Lei nº 14.789/2023 já começaram a irradiar efeitos desde o dia 1º de janeiro de 2024, devendo ser suspensos imediatamente, sob pena de causar prejuízos irreparáveis.

73. Com efeito, as pessoas jurídicas beneficiárias de subvenções realizam um planejamento de investimento de acordo com esses incentivos fiscais recebidos. A repentina tributação desses benefícios fiscais frusta os investimentos realizados e prejudica a competitividade dessas empresas. Portanto, o deferimento da presente tutela cautelar estaria em consonância com o princípio da segurança jurídica, tão necessário nas relações entre o Fisco e seus contribuintes.

74. Destarte, considerando a flagrante inconstitucionalidade, assim como o *periculum in mora* decorrente de sua aplicação, com todos os graves prejuízos relacionados, revela-se como imprescindível e urgente a decretação liminar, para suspender a eficácia dos arts. 1º a 12, 15, 16 e 21 da Lei nº 14.789/2023 até o julgamento final desta ação, ocasião em que deverá ser reconhecida a inconstitucionalidade dos mesmos de forma definitiva.

75. Assim, se evitará a continuidade da violação do texto constitucional, a insegurança jurídica daí decorrente e os danos causados às empresas, bem como à toda a sociedade.

IX – DOS PEDIDOS

76. Ante o exposto, requer:

(i) A concessão de tutela cautelar, previamente à solicitação de informações (conforme preceitua o art. 170 do Regimento Interno desta E. Corte), para suspender a aplicação dos arts. 1º a 12, 15, 16 e 21 da Lei nº 14.789/2023 até o julgamento final desta ação;

(ii) Após a concessão da tutela cautelar, sejam solicitadas informações ao Congresso Nacional, responsável pela edição do ato normativo aqui atacado;

(iii) Sejam ouvidos o Advogado Geral da União e o Procurador-Geral da República, na forma do art. 103, §§ 1º e 3º, da Constituição;

(iv) A procedência da presente ação direta de inconstitucionalidade, confirmando-se a tutela cautelar, para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 1º a 12, 15, 16 e 21 da Lei nº 14.789/2023.

Nesses termos,

Pede e espera deferimento.

Rio de Janeiro, 05 de abril de 2024.

Alain Alpin MacGregor
OAB/RJ 101.780

Bruno Murat do Pillar
OAB/RJ 95.245

ASSINADO DIGITALMENTE
CAMILA DA COSTA VIEIRA BLANCO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Camila Vieira Blanco
OAB/RJ 181.644